

1500118-91.2021.8.26.0574

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: MARIO HENRIQUE GEBRAN SCHIRMER

Comarca: Fartura

Foro: Foro de Fartura

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 22/03/2022

... em relação a associação para o tráfico (art. 35), em razão de não demonstrada a reiteração na prática delitativa e a estabilidade da organização; a improcedência em relação ao delito de tráfico de drogas (art. 33, da Lei 11.343/06), ao acusado Nelson; a procedência da denúncia de tráfico de drogas, em relação aos acusados Matheus e José Lucas; e, ainda, a condenação ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Fartura

Foro de Fartura

Vara Única

Rua Anacleto Gonçalves Neves, 250, Centro - CEP 18870-000, Fone: (14) 3382-1855,

Fartura-SP - E-mail: fartura@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo Digital nº:

1500118-91.2021.8.26.0574

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2118473/2021 - DEL.POL.TAQUARITUBA, 17660632 - DEL.POL.TAQUARITUBA, 463/21/108 -

DEL.POL.TAQUARITUBA, 2118473 - DEL.POL.FARTURA, 463/21/108 - DEL.POL.FARTURA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MATHEUS WILLIAN DA SILVA MATOS e outros

Vítima:

SAÚDE PÚBLICA e outro

Artigo da Denúncia:

*

Data da Audiência:

22/03/2022

Aos vinte e dois dias do mês de março de dois mil e vinte e dois, nesta cidade e Comarca de Fartura, Estado de São Paulo, na sala virtual de audiência, presente o MM. Juiz Substituto desta Comarca, Exmo. Sr. Dr. Mário Henrique Gebran Schirmer, comigo Escrevente Técnico Judiciário, no final nomeado e assinado, aí, após os pregões legais, verificou-se o comparecimento do DD. Promotor de Justiça, Exmo. Sr. Dr. Pedro Rafael Nogueira Guimarães, dos réus Matheus Willian da Silva Matos e Nelson de Oliveira Neto, acompanhados de seus defensores Dr. Denis Willian do Prado e Dra. Vania Colanzi de Carvalho; do réu José Lucas Vieira de Camargo, acompanhado de seu defensor Dr. Cleber Antonio Machado, das testemunhas Flávio Veríssimo dos Santos e William Wanderley Gomes Fabro, comuns entre a acusação e a defesa de José Lucas, e das testemunhas Luis Henrique Pocha Matos, Fernanda Cristina Huggler e Larissa Gabriela Meneguel, arroladas pela defesa de José Lucas. Instalada a

audiência, o MM. Juiz inquiriu as testemunhas comuns, o que foi registrado conforme depoimento gravado em arquivo de vídeo, que será juntado aos autos, nos termos do artigo 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional 45/2004; do artigo 154, § 2º e artigo 279 ambos do Código de Processo Civil; da Resolução nº 105/2010 do Conselho Nacional de Justiça – C.N.J., artigo 2º e § 2º; do artigo 405, § 1º e 2º do Código de Processo Penal e demais corolários legais à espécie. Na sequência, pelo DD. Juiz foram ouvidos, na condição de informante, Luis Henrique Pocha Matos e Larissa Gabriela Meneguel, o que foi registrado conforme depoimento gravado em arquivo de vídeo, que será juntado aos autos, nos termos do artigo 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional 45/2004; do artigo 154, § 2º e artigo 279 ambos do Código de Processo Civil; da Resolução nº 105/2010 do Conselho Nacional de Justiça – C.N.J., artigo 2º e § 2º; do artigo 405, § 1º e 2º do Código de Processo Penal e demais corolários legais à espécie. A seguir, pelo Dr. Defensor do réu José Lucas Vieira de Camargo foi feita a seguinte manifestação: “MM. Juiz, desisto do depoimento da testemunha Fernanda Cristina Huggler”. A seguir, pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte deliberação: “Homologo a desistência da testemunha, formulada pela defesa de José Lucas Vieira de Camargo.” Após, os réus José Lucas Vieira de Camargo, Nelson de Oliveira Neto e Matheus Willian da Silva Matos, nesta ordem, foram interrogados, o que foi registrado conforme depoimento gravado em arquivo de vídeo, que será juntado aos autos, nos termos do artigo 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional 45/2004; do artigo 154, § 2º e artigo 279 ambos do Código de Processo Civil; da Resolução nº 105/2010 do Conselho Nacional de Justiça – C.N.J., artigo 2º e § 2º; do artigo 405, § 1º e 2º do Código de Processo Penal e demais corolários legais à espécie. Em seguida, pelo MM. Juiz foi encerrada a instrução e perguntado às partes se havia algum requerimento de diligências, nos termos do artigo 402 do CPP, sendo que não houve qualquer requerimento, passando-se então aos debates. Dada a palavra ao Dr. Promotor de Justiça, por ele foi feita a seguinte manifestação, o que foi registrado conforme depoimento gravado em arquivo de vídeo, que será juntado aos autos, nos termos do artigo 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional 45/2004; do artigo 154, § 2º e artigo 279 ambos do Código de Processo Civil; da Resolução nº 105/2010 do Conselho Nacional de Justiça – C.N.J., artigo 2º e § 2º; do artigo 405, § 1º e 2º do Código de Processo Penal e demais corolários legais à espécie. A seguir, foi dada a palavra ao Dr. Defensor do réu José Lucas Vieira de Camargo, o que foi registrado conforme depoimento gravado em arquivo de vídeo, que será juntado aos autos, nos termos do artigo 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional 45/2004; do artigo 154, § 2º e artigo 279 ambos do Código de Processo Civil; da Resolução nº 105/2010 do Conselho Nacional de Justiça – C.N.J., artigo 2º e § 2º; do artigo 405, § 1º e 2º do Código de Processo Penal e demais corolários legais à espécie. A seguir, foi dada a palavra aos Drs. Defensores dos réus Matheus Willian da Silva Matos e Nelson de Oliveira Neto, o que foi registrado conforme depoimento gravado em arquivo de vídeo, que será juntado aos autos, nos termos do artigo 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional 45/2004; do artigo 154, § 2º e artigo 279 ambos do Código de Processo Civil; da Resolução nº 105/2010 do Conselho Nacional de Justiça – C.N.J., artigo 2º e § 2º; do artigo 405, § 1º e 2º do Código de Processo Penal e demais corolários legais à espécie.

Posteriormente, pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte sentença:

“Trata-se de AÇÃO PENAL proposta pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em desfavor de NELSON DE OLIVEIRA NETO, JOSÉ LUCAS VIEIRA DE CAMARGO e MATHEUS WILLIAN DA SILVA MATOS, já qualificados nos autos, pela suposta prática dos delitos previstos nos art. 33, caput, e art. 35, caput, ambos da Lei 11.343/06, e, ainda, especificamente em relação ao acusado NELSON, a suposta prática do crime previsto no art. 310, do CTB.

A denúncia foi apresentada nos seguintes termos:

“(Fato 01) Consta do incluso Inquérito Policial que, em data e local não conhecidos, mas antes da noite do dia 1º de maio de 2021, nesta cidade e Comarca de Fartura/SP, MATHEUS WILLIAN DA SILVA MATOS, qualificado em fl. 22, JOSÉ LUCAS

VIEIRA DE CAMARGO, qualificado em fl. 46, e NELSON DE OLIVEIRA NETO, qualificado em fl. 206, associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente, o crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.

(Fato 02) Consta, também, que, no dia 1º de maio de 2021, na residência situada na Rua Germano de Oliveira, nº 90, em horário ignorado, mas antes das 8h45min, nesta cidade e Comarca de Fartura, NELSON DE OLIVEIRA NETO entregou a direção de veículo automotor, consistente na motocicleta da marca/modelo Honda/CG 160 Fan, placa EMQ-2760, de cor preta, ano modelo e fabricação de 2019, Renavam 01203643648, chassi 9C2KC2200KR124057, a José Lucas Vieira de Camargo, pessoa não habilitada.

(Fato 03) Consta que, no dia 1º de maio de 2021, em via pública, na Rua Máximo Perini, defronte ao número 750, Centro, por volta das 8h45min, nesta cidade e Comarca de Fartura, MATHEUS WILLIAN DA SILVA MATOS, JOSÉ LUCAS VIEIRA DE CAMARGO e NELSON DE OLIVEIRA NETO, agindo com unidade de desígnios e identidade de propósitos, transportaram, no interior do veículo automotor, consistente na motocicleta da marca/modelo Honda/CG 160 Fan, placa EMQ-2760, de cor preta, ano modelo e fabricação de 2019, Renavam 01203643648, chassi 9C2KC2200KR124057, 02 (duas) porções de maconha, pesando aproximadamente 13,7 g (treze gramas e sete decigramas), conforme boletim de ocorrência de fls. 3/6, auto de exibição e apreensão de fl. 7 e auto de constatação preliminar de substância entorpecente de fl. 9, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Segundo apurado, os denunciados estavam associados para a prática do crime de tráfico de drogas. Na data dos fatos, colocando em prática os fins para os quais referida associação fora constituída, o denunciado NELSON DE OLIVEIRA NETO entregou a sua motocicleta ao acusado JOSÉ LUCAS VIEIRA DE CAMARGO, pessoa não habilitada; este, por sua vez, entregou a direção do veículo a MATHEUS WILLIAN DA SILVA MATOS, que estava com a habilitação cassada, com o fito de realizar o transporte de droga para fins de tráfico.

Na ocasião, o denunciado MATHEUS WILLIAN DA SILVA MATOS estava na condução do veículo portando duas porções de maconha, enquanto, na garupa, JOSÉ LUCAS VIEIRA DE CAMARGO portava uma balança de precisão com resquícios de maconha, fatos estes de conhecimento de NELSON DE OLIVEIRA NETO, que deixou o veículo disponível para estes praticarem o comércio de drogas.

O fato foi descoberto porque a polícia militar abordou a motocicleta, que estava na condução de MATHEUS WILLIAN DA SILVA MATOS, com JOSÉ LUCAS VIEIRA DE CAMARGO na garupa, ocasião em que os policiais encontraram e apreenderam as drogas e petrecho acima mencionados.

Os três denunciados possuem denúncias no meio policial sobre a prática do comércio ilegal de drogas na cidade de Fartura/SP.

Pelas circunstâncias dos fatos, anteriores denúncias do envolvimento dos denunciados com o tráfico de drogas, empréstimo do veículo por parte do denunciado NELSON DE OLIVEIRA NETO; substâncias entorpecentes apreendidas na posse de MATHEUS WILLIAN DA SILVA MATOS, que estava na condução da motocicleta, e apreensão de balança de precisão com resquícios de entorpecentes na posse de JOSÉ LUCAS VIEIRA DE CAMARGO, que estava na garupa da motocicleta e recebeu emprestado o veículo do denunciado NELSON DE OLIVEIRA NETO, sendo que posteriormente JOSÉ LUCAS VIEIRA DE CAMARGO entregou a direção do veículo ao denunciado MATHEUS WILLIAN DA SILVA MATOS, todos esses fatos em conjunto comprovam a prática da traficância, seu dolo e que eles estavam associados para tal fim." (fls. 212-214).

Os acusados José Lucas e Matheus foram presos em flagrantes, sendo as prisões homologadas e concedida liberdade provisória ao acusado Matheus e decretada a prisão preventiva do acusado José Lucas (fls. 89-93). Posteriormente, em razão de decisão do e. STJ, foi concedida liberdade provisória ao acusado José Lucas (fls. 296-309).

Os acusados apresentaram defesa prévia (fls. 254-260; 272-279; 281-288).

A denúncia foi recebida na data de 15 de outubro de 2021, não sendo concedida absolvição sumária e sendo determinada a realização de audiência de instrução e julgamento (fls. 333-336).

Foi produzida a prova oral, com a oitiva das testemunhas e os interrogatórios dos

acusados, por meio de sistema de gravação audiovisual, em audiência realizada por videoconferência, nos termos do Comunicado CG nº 284/2020.

Encerrada a fase de instrução, o i. representante do Ministério Público, em sede de alegações finais, pleiteou pela parcial procedência da ação, argumentando a improcedência, em relação a associação para o tráfico (art. 35), em razão de não demonstrada a reiteração na prática delitiva e a estabilidade da organização; a improcedência em relação ao delito de tráfico de drogas (art. 33, da Lei 11.343/06), ao acusado Nelson; a procedência da denúncia de tráfico de drogas, em relação aos acusados Matheus e José Lucas; e, ainda, a condenação do acusado Nelson, em relação ao crime do art. 310, do CTB. Sustentou que a situação apresentada indica à realização do tráfico de drogas, em razão dos apetrechos apreendidos e das versões apresentadas. Na dosimetria, postulou pela fixação de regime inicial fechado ao acusado José Lucas, bem como a possibilidade de aplicação de institutos despenalizadores ao acusado Nelson, em relação ao crime do art. 310, do CTB.

A defesa de José Lucas alegou, em síntese, que inexistem provas suficientes à condenação. Argumentou que não demonstrada a traficância, pois o acusado é somente usuário de drogas. Pugnou, ainda, pela desclassificação ao art. 28, da Lei de Drogas.

A defesa de Nelson e Matheus sustentou, em síntese, que inexistem provas suficientes à condenação, bem como os fatos comprovados não constituem infração penal. Afirmou que a traficância não restou demonstrada, bem como as circunstâncias de apreensão não indicam à prática do crime do art. 33, da Lei 11.343/06. Em relação ao crime do art. 310, do CTB, sustentou que inexistente dolo na conduta. Sustentou que devida a desclassificação ao art. 28, da Lei 11.343/06, em relação ao acusado Matheus. Subsidiariamente, postulou pelo reconhecimento do crime do art. 33, §4º, da Lei de Drogas.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

1. Os acusados Matheus e Nelson alega, em preliminar, a inépcia da inicial. No ponto, observo que a preliminar de inépcia já foi devidamente afastada às fls. 333-336.

Não sem razão. A satisfação dos pressupostos que afastam a inépcia se concretiza mediante a imputação de todos os pressupostos do ato ilícito e a descrição da conduta imputada ao acusado. Nesse sentido, a denúncia deve descrever indícios mínimos de autoria, materialidade, tipificação de conduta que, em tese, seja ilícita e apresentação de justa causa. Tratam-se, pois, dos requisitos do art. 41, do CPP.

"1. Não se reconhece a inépcia quando a denúncia preenche aos requisitos do art. 41 do CPP, com a descrição dos fatos e a classificação do crime, (arts. 215 e 217-A/CP) de forma suficiente para dar início à persecução penal na via judicial, bem como para o pleno exercício da defesa." (AgRg no RHC 143.396/MG, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 20/08/2021).

"5. Afasta-se a alegação de inépcia da denúncia quando a peça inicial acusatória atende os requisitos mínimos previstos no art. 41 do Código de Processo Penal, com a exposição de indícios mínimos de autoria e materialidade, que consubstanciam justa causa para a ação penal." (AgRg no REsp 1463883/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 20/08/2021).

In casu, todos estes requisitos estão preenchidos, dado que a denúncia indicou de maneira suficiente a conduta que é imputada ao acusado, bem como apresentou indícios de materialidade e autorias, além de atribuir tipificação, a priori, ao agir dos réus.

Rejeitada a preliminar, passo à análise do mérito.

2. Antes, todavia, são necessários alguns apontamentos a respeito do standard probatório reclamado para a legitimação de uma condenação na seara penal. Afinal, a imposição de quaisquer penalidades pressupõe, para sua validade, não apenas o efetivo exercício de coerção, antes exigindo, também, que o poder estatal esteja

assentado em premissas discursivas de legitimação (a respeito ver: FORST, Rainer. Justificação e Crítica – perspectivas de uma teoria crítica da política. São Paulo: Editora Unesp, 2018; ARENDT, Hannah. Sobre a Violência. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2009). Trata-se, ao fim e ao cabo, da necessidade de justificação do poder, o que é inerente ao próprio conceito de democracia.

Nesse contexto, a imposição de penas exige que o decreto condenatório esteja alicerçado em provas e fundamentos que conduzam a uma conclusão que se coloca além de um patamar de 'dúvida razoável' a respeito da existência e autoria delitivas. Neste sentido é a doutrina de Gustavo Badaró, ao afirmar que, conquanto a atividade probatória ambicione a reconstrução de fatos históricos – os quais, por evidente, não podem ser reproduzidos de maneira idêntica e absoluta –, nas hipóteses de procedência da pretensão punitiva deverá ser alcançada uma conclusão assentada em um "altíssimo grau de probabilidade" de ocorrência de fatos tais como narrados na denúncia (BADARÓ, Gustavo. Ônus da prova no processo penal. São Paulo: Editora RT, 2003, p. 62). Isto se traduz, em síntese, em afirmar que a possibilidade de condenação está à mercê da maior ou menor solidez do contexto probatório que se está inserido, sendo, no entanto, necessário, sempre, um mínimo de lastro probatório para que se possa proferir um decreto condenatório.

Diante disso, não se pode olvidar que, de maneira geral, a legislação e a jurisprudência pátrias pouco se ocuparam do estabelecimento de qual seria este 'nível probatório mínimo' exigível para um decreto condenatório, quase sempre se restringindo somente a lançar mão dos conceitos de 'persuasão racional' e 'livre convencimento do juiz'.

Em contrapartida, a experiência estrangeira tem evidenciado a importância da fixação de um parâmetro da existência de prova "acima de uma dúvida razoável" (proof beyond a reasonable doubt). https://www.google.com.br/search?q=Federal+Judicial+Center,+Pattern+Criminal+Jury+Instructions.&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=psCBVaPWbCy5ggT6mK-ADQ

Portanto, se é verdade que a natureza temporal das provas – enquanto pretensão da reconstrução histórica de fatos – importa no reconhecimento da inexistência de verdades ou provas absolutas, é igualmente verdade que a exigência de um standard de "prova acima de uma dúvida razoável" se traduz em mecanismo que impede a livre valorização dos fatos a bel-prazer arbitrário de cada julgador.

Ainda assim, nas excepcionais oportunidades em que a temática foi analisada pelas Cortes pátrias, foi destacada a imprescindibilidade de que o standard probatório esteja em patamar 'acima de dúvida razoável'. Nesse sentido, o e. Supremo Tribunal Federal já afirmou a importância de demonstrar a ocorrência de fatos 'para além de dúvida razoável':

“DIREITO PENAL. AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA. OPERAÇÃO SANGUESSUGA. FRAUDE EM LICITAÇÃO. CRIME DO ART. 90 DA LEI 8.666/1993. CORRUPÇÃO PASSIVA. QUADRILHA. DEPUTADO FEDERAL. FALTA DE PROVA HÁBIL. ABSOLVIÇÃO. 1. A presunção de inocência, princípio cardeal no processo criminal, é tanto uma regra de prova como um escudo contra a punição prematura. Como regra de prova, a melhor formulação é o "standard" anglo-saxônico - a responsabilidade criminal há de ser provada acima de qualquer dúvida razoável -, consagrado no art. 66, item 3, do Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional. 2. A falta de prova suficiente da participação do acusado, Deputado Federal, nos crimes licitatórios praticados com verbas decorrentes de emendas parlamentares de sua autoria, bem como do recebimento de vantagem indevida em decorrência das emendas parlamentares e, ainda, de associação a grupo dedicado à prática de fraudes e peculatos na aquisição de ambulâncias com recursos federais, impõe-se a absolvição. 3. Ação penal julgada improcedente.” (AP 521, Relatora Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, publicado em 06-02-2015 - destaquei)

“Queixa-crime ajuizada contra parlamentar. Injúria. Delito praticado por meio de matéria divulgada em periódico escrito. Alegada falta de justa causa por inexistência de dolo específico voltado a atingir a honra da vítima. Necessidade da dilação probatória. Subsunção dos fatos à conduta típica descrita na inicial acusatória. Queixa recebida. 1. A verificação acerca da narração de fato típico, antijurídico e culpável, da inexistência de causa de extinção da punibilidade e da presença das condições exigidas pela lei para o exercício da ação penal (aí

incluída a justa causa) revela-se fundamental para o juízo de admissibilidade de deflagração da ação penal. A inexistência de dolo específico é questão que deve situar-se no âmbito da instrução probatória, por não comportar segura ou precisa análise nesta fase processual, que é de formulação de um simples juízo de delibação. 2. As condutas em foco, todavia, se amoldam, em tese, ao delito invocado na peça acusatória, sendo que a defesa apresentada pelo querelado não permite concluir, de modo robusto, ou para além de toda dúvida razoável, pela improcedência da acusação. 3. Queixa recebida.” (Inq 2968, Relator Ministro Dias Toffoli, Tribunal Pleno, publicado em 17-08-2011 - destaquei).

O Superior Tribunal de Justiça já adotou idêntico posicionamento:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. ART. 2º DA LEI N. 8.176/1991 E ART. 55 DA LEI N. 9.605/1998. CONCURSO FORMAL. PRESCRIÇÃO. FALTA DE PROVAS. (...) 5. O estado jurídico de inocência, corolário da dignidade da pessoa humana, exige para a condenação a certeza além da dúvida razoável, não sendo admissível sequer a alta probabilidade. Ausentes elementos de prova aptos a demonstrar os fatos imputados, devem os réus ser absolvidos com fundamento no art. 386, II, do CPP. Ação penal julgada improcedente, absolvendo-se os acusados com fundamento no art. 386, II, do CPP”. (APn 719/DF, Rel. Ministro Humberto Martins, Corte Especial, DJe 18/11/2014 - destaquei).

Feitas tais considerações gerais a respeito dos níveis probatórios necessários a comportar um decreto condenatório, passo ao exame dos elementos de prova existentes nos autos para atestar a comprovação, ou não, da prática dos delitos imputados aos réus.

3. Analisando-se os elementos de informação, bem como a produção de provas em juízo, verifico que a materialidade está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01-02), auto de exibição e apreensão (fl. 07), foto (fl. 08), auto constatação preliminar (fl. 09), laudo pericial (fls. 235-238), ofício encaminhado pelo Detran/SP (fls. 322-326) e prova oral produzida em juízo.

4. Passo às considerações a respeito da autoria.

A testemunha William (policial militar) relatou, em síntese que estava em companhia de seu companheiro de patrulhamento, quando avistou os acusados, em uma motocicleta, tendo notado que um deles era Matheus. Considerando que Matheus era conhecido dos meios policiais, inclusive, com conhecimento de que não poderia dirigir, procederam com a abordagem. Em busca pessoal, encontraram com Matheus duas porções de maconha e com o acusado José Lucas encontraram uma balança de precisão. Matheus alegou que a droga era para consumo próprio e José Lucas disse que havia encontrado a balança na rua pouco antes. Sobre a moto, Matheus disse que pegou o veículo emprestado com Nelson para buscar José Lucas. Esclareceu que existiam informações anônimas de pessoas do bairro implicando os acusados na venda de drogas. Disse que Matheus afirmou que a droga era para consumo próprio. Não recorda se foram apreendidos valores com os acusados. Afirmou que no dia dos fatos não teve contato com a pessoa de Nelson.

A testemunha Flávio (policial militar) narrou, em síntese, que estava em patrulhamento e notaram que duas pessoas, sendo uma dessas pessoas Matheus, que é conhecido dos meios policiais. Então, realizaram a abordagem sendo que com Matheus encontraram duas porções de drogas e com José Lucas encontraram uma balança de precisão. Relatou que Matheus disse que a droga seria para uso e não recorda o que José Lucas falou, sendo que não conhecia este antes dos fatos. Afirmou que a moto foi entregue a José e Matheus por terceiro, mas não recorda o nome da pessoa que forneceu o veículo. Disse que nunca recebeu informação de que José Lucas estivesse envolvido com o tráfico e que existem diversas informações envolvendo Matheus, quem disse que a droga seria para uso próprio.

Os informantes Luís Henrique e Larissa apresentaram relatos abonatórios em relação ao acusado José Lucas.

Em Juízo, o acusado José Lucas narrou, em síntese, que no dia dos fatos emprestou a moto com Nelson para buscar Matheus. Que no caminho pegou sua balança de precisão, a qual usa para pesar drogas, pois é consumidor de entorpecentes (maconha e

cocaína). Afirmou que no dia disse ter encontrado a balança na rua, mas na verdade a balança é sua. Que Matheus não sabia que ele estava com a balança de precisão e ele não sabia que Matheus estava com droga. Disse que com Matheus estava indo ao aniversário de sua amásia. Afirmou que ainda é usuário dos entorpecentes.

Em Juízo, o acusado Nelson disse, em síntese, que o dia era um sábado de manhã, aniversário da esposa de José Lucas, e ele estava na casa do acusado. Então, José Lucas saiu com sua moto, mas não sabia disso. Então, foi informado por um terceiro que a moto estava sendo apreendida. Afirmou que estava na casa de José Lucas e ele na casa da esposa dele. Relatou que não viu José Lucas saindo com a moto e mencionou que José Lucas as vezes pegava sua moto, sendo que no dia dos fatos falou que sairia, mas não mencionou que era com a sua moto.

Em Juízo, o acusado Matheus negou a prática do delito, dizendo que é usuário de drogas. Afirmou que no dia dos fatos, iria usar maconha quando chegou José Lucas lhe oferecendo para ir ao aniversário da esposa dele. Disse que José Lucas lhe passou a moto, porque José Lucas não é muito bom na condução. Confirmou que a droga era sua.

5. Diante deste contexto, entendo que autoria e materialidade estão parcialmente comprovadas.

5.1. No ponto, ressalto, em primeiro lugar, que as testemunhas narraram com clareza e de forma detalhada como se deram os fatos. Além disso, não há nos autos indícios de que elas tenham se manifestado de maneira maliciosa e temerária, imputando falsamente à prática criminosa aos acusados. Ao contrário, o que se observa é que as testemunhas asseveraram com precisão o desdobramento do fato, imprimindo certeza e seriedade em suas narrativas.

Ainda neste contexto, em relação ao depoimento dos policiais militares, a jurisprudência, há muito, já firmou entendimento de que o testemunho dos policiais tem valor idêntico aos de outras pessoas quaisquer que não possuam qualquer interesse no julgamento. Por todos, veja-se o posicionamento do e. Supremo Tribunal Federal:

"VALIDADE DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE AGENTES POLICIAIS. - O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. - O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos. Doutrina e jurisprudência." (HC 73518, Relator(a): CELSO DE MELLO, Primeira Turma, julgado em 26/03/1996, DJ 18-10-1996 PP-39846 EMENT VOL-01846-02 PP-00293).

E, também, do STJ:

"3. A jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (HC n. 477.171/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018)." (AgRg no AREsp 1770014/MT, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 15/12/2020)".

5.2. O acusado Matheus confirmou que estava com a droga, argumentando, no entanto, que a substância era para uso próprio. Desta maneira, não há dúvidas a respeito da autoria, ficando as questões controversas ressaltadas ao plano da tipicidade.

A participação de Nelson no suposto tráfico de drogas não foi, em momento algum, mencionada. O acusado não estava presente no momento da apreensão e não existem quaisquer elementos que indiquem ao fato de que o acusado Nelson teria contato ou conhecimento de que Matheus trazia drogas consigo. Não por outra razão, o i. representante do Ministério Público pugnou por sua absolvição.

Finalmente, a participação do acusado José Lucas nos fatos restou controversa, não

atendendo ao standard probatório exigido para uma condenação penal. Com efeito, existem alguns indícios que permitem presumir que o acusado soubesse que Matheus trazia drogas consigo. No entanto, tal pressuposição está suficientemente fundamentada, sobretudo diante das negativas dos acusados de que reciprocamente soubesse dos bens que o outro carregavam.

Note-se que ambos os acusados afirmaram que desconheciam que o outro trazia os bens apreendidos consigo. Ademais, conforme se verá adiante, a hipótese de que os acusados pretendiam realizar o tráfico de drogas não está suficientemente demonstrada e, portanto, torna-se, ainda mais, dificultoso presumir que o acusado José Lucas aderiria a conduta do acusado Matheus.

5.3. Em relação ao crime do art. 310, do CTB, a situação é peculiar. Diante dos relatos apresentou, conclui-se que Nelson emprestou a motocicleta à pessoa de José Lucas, quem, ao que se compreende, não pediu o veículo, mas procedeu com o 'empréstimo', pois tal situação é costumeira. Porém, posteriormente, José Lucas passou a condução do veículo à pessoa de Matheus – este sim não habilitado, conforme demonstrado às fls. 322-326. No entanto, tal situação ocorreu sem o conhecimento do acusado Nelson, o que implica em inexistência do dolo, dado que um dos elementos fundamentais do elemento subjetivo não faz presente. Portanto, verifica-se que Nelson não emprestou o veículo à pessoa não habilitada. Ao contrário, permitiu que José Lucas (pessoa habilitada) emprestasse sua motocicleta, sendo esse quem confiou o veículo a Matheus – este, sim, não habilitado. Dessa maneira, entendo que estão comprovadas autorias e materialidades da conduta descrita na exordial.

6. Por esta razão, passa à análise do tipo penal.

6.1. Como se sabe, para a caracterização do delito previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, não se faz necessário que o acusado seja surpreendido no próprio ato da mercancia ilícita. Isto porque o tipo penal exposto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, é um crime de núcleo misto e alternativo, para o qual basta a configuração de uma das condutas nucleares do tipo para que esteja comprovada a prática penal.

Nesse sentido, observe-se a redação do art. 33, da Lei 11.343/06: “Art.33: Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor a venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar”. (grifo nosso).

Entretanto, embora se trate de tipo plurinuclear alternativo, faz-se necessária a comprovação do dolo na prática da traficância – isto é, a demonstração de que o agir nuclear do tipo se orienta pela finalidade do cometido do ato de tráfico de drogas.

Não sem razão.

Tratando-se delito que expõe diversas ações como típicas, faz-se imprescindível que o cometido da conduta esteja orientado pela finalidade do delito – eis, aqui, um exemplo sintomático da adoção da teoria finalística –, sob pena de tipicidade do art. 33, da Lei 11.343/06, dissolva-se para demais espécies penais, violando, assim, a legalidade penal. Por exemplo, a conduta de 'trazer consigo' ou 'transportar' são espécies nucleares do tipo do art. 33, da Lei de Drogas, porém são também hipóteses que, por vezes, inerentes ao uso de drogas (art. 28). Daí a imperiosa necessidade de demonstrar que a comprovação da conduta típica está orientada pela finalidade de traficância.

No caso em análise, entendo que, a despeito da comprovação do fato de que os acusados traziam consigo a droga, há dúvida a respeito da efetiva traficância. É que, embora esteja comprovado que o acusado Matheus inequivocamente em posse das drogas, há, pelo menos, 'razoável dúvida', a respeito de qual era sua intenção ao transportá-las.

Isto porque, a despeito da posse, não restou caracterizado, de maneira a satisfazer o standard probatório do processo penal, que os acusados tivessem a intenção de distribuição ou comercialização a terceiros as substâncias apreendidas com eles. No ponto, observe-se que a quantidade de entorpecentes apreendidos é bastante

modesta (13,7g de maconha), não foi observado ou constatado nenhum ato de traficância e os acusados, sempre que ouvidos, disseram que pretendiam utilizar a droga.

Não se olvida que existem alguns indícios que podem, eventualmente, indicar a traficância (porções individualizadas de drogas, ausência de apetrechos para o uso, pequenas contradições nos depoimentos dos acusados, apreensão de balança de precisão). No entanto, tais circunstâncias não demonstram de maneira segura que os acusados pretendiam traficar, não sobrepujando, pois, o ônus probatório inerente ao processo penal, na medida em que se permite inferir a existência de cenários que implicariam em um lapso lógico entre as premissas (acusados estavam em posse das drogas) e conclusões (acusados estavam traficando).

Em outras palavras: há, não se olvide, elementos que autorizam a suposição/suspeita de que os acusados estavam cometendo o delito previsto no art. 33, da Lei 11.343/06. No entanto, não existem elementos probatórios suficientes para assegurar que os acusados tenham realmente cometido tal crime, em especial porque são cogitáveis hipóteses que preencham as circunstâncias iniciais (posse das drogas) e não conduzam, necessariamente, a conclusão de que os acusados estavam traficando. Ao fim e ao cabo, são possíveis pressuposições circunstâncias, que fundamentem um juízo de possibilidade. Porém, diante do contexto probatório, não é viável uma conclusão segura, que conduza a satisfação do standard probatório exigido para uma condenação penal.

Nesse sentido, entendo que há razoável dúvida a respeito da prática do delito previsto no art. 33, da Lei 11.343/06.

6.1.1. No entanto, considerando as alegações dos acusados e a comprovação da autoria e materialidade, entendo que caracterizada a conduta descrita no art. 28, da Lei 11.343/03.

No ponto, ressalvo meu entendimento pessoal, no sentido que a tipificação estabelecida no art. 28, da Lei 11.343/06, padece de inconstitucionalidade, na medida em que, em decorrência do princípio da lesividade/ofensividade penal – o qual decorre diretamente do direito de liberdade, previsto no art. 5º, caput, e X, da CF –, é incompatível com a ordem constitucional a criminalização de condutas que não atinjam bens jurídicos de terceiros.

É que, conforme bem expôs John Stuart Mill, em seu célebre ensaio Sobre a Liberdade: “só o dano para os interesses de outros – ou a probabilidade elevada de haver dano – pode justificar a interferência da sociedade” (MILL, John Stuart. Sobre a Liberdade. Tradução de Pedro Madeira. Rio de Janeiro: Almeidina/Saraiva, 2011, p. 86).

“Nenhuma pessoa devia ser punida simplesmente por estar bêbada; mas um soldado ou um polícia devia ser punido por estar bêbado em serviço. Resumindo: sempre que há um dano claro, ou um risco claro de dano, quer para um indivíduo quer para o público, o caso é retirado do campo da liberdade e colocado no da moralidade ou da lei.

Mas em relação ao dano meramente contingente ou, como pode ser chamado, estrutural, que uma pessoa causa à sociedade através de conduta que nem viola qualquer dever específico para com o público, nem dá azo a danos perceptíveis para qualquer indivíduo definido senão ela mesma, a sociedade pode dar-se ao luxo de suportar essa inconveniência, tendo em vista o bem maior da liberdade humana. Se fosse para punir adultos por não tomarem bem conta de si, preferia que fosse para seu próprio bem, e não com o falso pretexto de os impedir de diminuir a sua capacidade de prestar à sociedade benefícios que esta não finge ter o direito de exigir. Mas não posso aceitar discutir o assunto como se a sociedade não tivesse quaisquer outros meios de elevar os seus membros mais fracos ao padrão normal da conduta racional, a não ser esperar que fizessem algo irracional, e depois puni-los, legal ou moralmente, por isso.” (MILL, John Stuart. Sobre a Liberdade. Tradução de Pedro Madeira. Rio de Janeiro: Almeidina/Saraiva, 2011, p. 77).

A posição não é distinta na doutrina jurídica.

Conforme exposto, pelo Prof. Salo de Carvalho, em sua tese de mestrado, A Política Criminal de Drogas no Brasil:

"O princípio da lesividade ou da ofensividade complementa, de forma organizativa, o princípio da intervenção mínima. O princípio dispõe que somente poderá ser aplicada penalidade no momento em que a ação infrinja bem jurídico determinado, produzindo-lhe dano - resultado material. Quatro funções específicas são delineadas pelo princípio da lesividade, segundo Nilo Batista: a. proibição de incriminações de atitudes internas; b. proibição de criminalizar condutas que não excedam o âmbito do próprio autor; c. proibição de incriminações de simples estados ou condições existenciais; e, d. proibição de criminalização de condutas desviadas que não afetem qualquer bem jurídico específico. [...].

Sobre a incriminação de atos que não excedam o próprio autor, o princípio se refere à proibição de incriminação de autolesões, crimes impossíveis e atos preparatórios. Relativo ao caso das drogas, toma-se questão fundamental a análise do bem jurídico tutelado e a potencialidade da lesão, principalmente nas condutas usuais."

(CARVALHO, Salo. A Política de Drogas no Brasil, dissertação de mestrado apresentada ao Programa de Pós-graduação em Direito da UFSC, 1996, p. 108-109 - negrito original, grifos próprios).

Também nesse sentido:

"A despeito da importância dada por alguns autores funcionalistas ao conceito de bem jurídico para a afirmação da subsidiariedade e da fragmentariedade do Direito Penal, a existência e tutela penal do bem jurídico somente tem importância se esse conceito for considerado em conjunto com a ofensividade mínima que se exige para a caracterização da tipicidade material do delito (ZAFFARONI, et all., 2010, p. 212). [...].

Em face do princípio da lesividade ao bem jurídico, para E. Raúl Zaffaroni, são ilegítimas incriminações penais que imponham uma determinada moral ou que tenham conteúdo simbólico (ZAFFARONI, et all., 2010, p. 221). Postula também a ilegitimidade do uso da legislação penal a situações em que, embora absolutamente ineficaz para os resultados a que se destina, talvez até mesmo agravando-os, o legislador utiliza-a para tranquilizar a opinião pública e de este modo, proveer al clientelismo político (ZAFFARONI, et all, 2002, p. 489).

Nesse sentido, é de reconhecer-se como função da ofensividade a limitação ao Poder Legislativo, uma vez que devem ser consideradas inconstitucionais as intervenções penais que criminalizam condutas que não ofendem ou sequer geram perigo concreto de lesão a bens jurídicos.

Esses limites impostos ao legislador quando da incriminação de condutas foram sistematizados por Nilo Batista, ao afirmar que o princípio da lesividade tem as seguintes funções: a) proibir a incriminação de uma atitude interna; b) proibir a incriminação de uma conduta que não exceda o âmbito do próprio autor; c) proibir a incriminação de simples estados ou condições existenciais; e d) proibir a incriminação de condutas desviadas que não afetam qualquer bem jurídico, tendo-se por desviada a conduta fortemente desaprovada pela coletividade (BATISTA, 1999, p. 92 e ss).

De fato, não se pode deixar de constatar a inconstitucionalidade de intervenções estatais desse jaez, na medida em que a Constituição consagra o direito à liberdade de opinião e de expressão (art. 5º, IV, VI), a inviolabilidade da intimidade e da vida privada (art. 5º, X) e o pluralismo político e social (art. 3º, IV).

Assim, manifesta-se a inconstitucionalidade de intervenções estatais com tais conteúdos na medida em que reduzem direitos fundamentais, sem que qualquer finalidade social possa ser antevista nessas intervenções. As intervenções estatais são inconstitucionais se não tiverem por finalidade assegurar os objetivos da República Federativa do Brasil expressos no art. 3º da CR/88. Pelo contrário, o que se vislumbra em incriminações sem ofensa a bens jurídicos é que elas não apenas distanciam a sociedade brasileira de uma sociedade livre (art. 3º, I, CR/88) como ainda ampliam a marginalização, que é objetivo estatal eliminar (art. 3º, III, CR/88). Não se pode perder de vista que: O mais importante compromisso vinculador da atuação do Estado brasileiro decorrente da natureza de nossa Constituição (pacto social) é o reconhecimento da existência de um núcleo inviolável de direitos, constituído pelos direitos fundamentais, cuja tutela é prioridade máxima do Estado

e que não podem ser suprimidos nem mesmo a pretexto de atender à vontade da ampla maioria ou ao consenso existente na sociedade. (BRODT, 2005, p. 33)." (ÂREDE, Sirlene Nunes. O Princípio da Ofensividade e a Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, in: Revista CEJ, Brasília, Ano XV, n. 55, p. 36-45, out./dez. 2011, p. 37-38).

Além disso, não se pode olvidar que tramita, perante o Supremo Tribunal Federal, Recurso Extraordinário (RE 635659), com questão de repercussão geral reconhecida, em que se discute a constitucionalidade da previsão normativa do art. 28, da Lei 11.343/06.

É certo que o caso ainda está pendente de julgamento definitivo. Porém, é igualmente inequívoco que os Ministros Gilmar Mendes (relator), Luís Roberto Barroso e Edson Fachin já proferiram votos no sentido de reconhecer a inconstitucionalidade.

Neste contexto, transcreve-se trecho paradigmático do voto do Ministro Relator:

"Nossa Constituição consagra a dignidade da pessoa humana e o direito à privacidade, à intimidade, à honra e à imagem. Deles pode-se extrair o direito ao livre desenvolvimento da personalidade e à autodeterminação.

A proteção do indivíduo contra interferências que se estimem indevidas por parte do Estado pode ser atalhada, dessa forma, com a invocação do princípio da liberdade geral, que não tolera restrições à autonomia da vontade que não sejam necessárias para alguma finalidade de raiz constitucional, e mesmo pelo apelo ao princípio da proteção da dignidade da pessoa humana, que pressupõe o reconhecimento de uma margem de autonomia do indivíduo, tão larga quanto possível, no quadro dos diversos valores constitucionais.

É sabido que as drogas causam prejuízos físicos e sociais ao seu consumidor. Ainda assim, dar tratamento criminal ao uso de drogas é medida que ofende, de forma desproporcional, o direito à vida privada e à autodeterminação.

O uso privado de drogas é conduta que coloca em risco a pessoa do usuário. Ainda que o usuário adquira as drogas mediante contato com o traficante, não se pode imputar a ele os malefícios coletivos decorrentes da atividade ilícita.

Esses efeitos estão muito afastados da conduta em si do usuário. A ligação é excessivamente remota para atribuir a ela efeitos criminais. Logo, esse resultado está fora do âmbito de imputação penal. A relevância criminal da posse para consumo pessoal dependeria, assim, da validade da incriminação da autolesão. E a autolesão é criminalmente irrelevante. São ilustrativos, nesse sentido, os exemplos citados por DANIEL PRADO (Boletim, IBCRIM, outubro/2012, p. 8-9), verbis: [...].

A criminalização da posse de drogas para uso pessoal conduz à ofensa à privacidade e à intimidade do usuário. Está-se a desrespeitar a decisão da pessoa de colocar em risco a própria saúde.

Não chego ao ponto de afirmar que exista um direito a se entorpecer irrestritamente. É perfeitamente válida a imposição de condições e restrições ao uso de determinadas substâncias, não havendo que se falar, portanto, nesse caso, em direito subjetivo irrestrito. Cabe registrar que, com esse mesmo entendimento, a Corte Constitucional alemã negou, em 1994, no julgamento do caso Cannabis, a existência de semelhante direito (Recht zum Rausch), afirmando, com isso, a viabilidade da criminalização do tráfico de cannabis sativa (BverfGE 90,145, 9.3.1994).

Também explicitou que o art. 2, I, da Lei Fundamental alemã, assegura o direito ao livre desenvolvimento da personalidade, mas que o uso de drogas, em especial graças à forte repercussão social que tem, não pode estar nele incluído. Não haveria, assim, um direito a "ficar intoxicado" ("Recht auf Rausch") assegurado pela Lei Fundamental.

O Tribunal considerou, todavia, que casos envolvendo posse, compra ou importação de pequenas quantidades de maconha para uso eventual devem ser desconsiderados pela insignificância de culpa e da proporção do dano causado.

De forma resumida, o §31 da lei alemã sobre narcóticos ("Betäubungsmittelgesetz") estabelece que a posse de pequenas quantias de drogas pode não ser criminalizada, exceto em caso de interesse público, e autoriza os promotores a encerrar o caso sem

consultar o Judiciário.

Ainda que se afirme que a posse de drogas para uso pessoal não integra, em sua plenitude, o direito ao livre desenvolvimento da personalidade, isso não legitima que se lance mão do direito penal para o controle do consumo de drogas, em prejuízo de tantas outras medidas de natureza não penal, como, por exemplo, a proibição de consumo em lugares públicos, a limitação de quantidade compatível com o uso pessoal, a proibição administrativa de certas drogas sob pena de sanções administrativas, entre outras providências não tão drásticas e de questionáveis efeitos como as sanções de natureza penal.

Na Espanha, por exemplo, entre as sanções administrativas previstas na legislação, há multas de até 30 mil euros e/ou a suspensão da carteira de motorista. São medidas, como se percebe, bem mais eficazes na contenção do consumo do que a simples aplicação de medidas penais sem resultados práticos demonstráveis.

Dessa forma, a prevenção do uso indevido de drogas, um dos princípios do sistema nacional de políticas públicas sobre drogas – art. 4º da Lei 11.343/06 – é uma finalidade estatal válida e pode ser alcançada, com maior eficácia, por meio de um vasto leque de medidas administrativas.

Nesse contexto, a criminalização do porte de drogas para uso pessoal afigura-se excessivamente agressiva à privacidade e à intimidade.

Além disso, o dependente de drogas e, eventualmente, até mesmo o usuário não dependente estão em situação de fragilidade, e devem ser destinatários de políticas de atenção à saúde e de reinserção social, como prevê nossa legislação – arts. 18 e seguintes da Lei 11.343/06. Dar tratamento criminal a esse tipo de conduta, além de andar na contramão dos próprios objetivos das políticas públicas sobre o tema, rotula perigosamente o usuário, dificultando sua inserção social.

A situação ainda é mais grave pela prevalência do consumo de drogas entre os jovens, pessoas em fase de desenvolvimento da personalidade e definição de vida e, por isso, especialmente sensíveis à rotulação decorrente do enquadramento criminal.

Da mesma forma, a percepção geral é de que o tratamento criminal aos usuários de drogas alcança, em geral, pessoas em situação de fragilidade econômica, com mais dificuldade em superar as consequências de um processo penal e reorganizar suas vidas depois de qualificados como criminosos por condutas que não vão além de mera lesão pessoal.

Assim, tenho que a criminalização da posse de drogas para uso pessoal é inconstitucional, por atingir, em grau máximo e desnecessariamente, o direito ao livre desenvolvimento da personalidade, em suas várias manifestações, de forma, portanto, claramente desproporcional.” (Voto do Ministro Relator Gilmar Mendes, no RE 635659 – grifos próprios).

Não distinto foi o posicionamento externado pelo Ministro Luís Roberto Barroso:

“VI. FUNDAMENTOS JURÍDICOS PARA A DESCRIMINALIZAÇÃO

Do ponto de vista jurídico, há pelo menos três fundamentos que justificam e legitimam a descriminalização à luz da Constituição:

1. Violação ao direito de privacidade

A intimidade e a vida privada, que compõem o conteúdo do direito de privacidade, são direitos fundamentais protegidos pelo art. 5º, X da Constituição. O direito de privacidade identifica um espaço na vida das pessoas que deve ser imune a interferências externas, seja de outros indivíduos, seja do Estado. O que uma pessoa faz na sua intimidade, da sua religião aos seus hábitos pessoais, como regra devem ficar na sua esfera de decisão e discricionariedade. Sobretudo, quando não afetar a esfera jurídica de um terceiro.

Ex. É preciso não confundir moral com direito. Há coisas que a sociedade pode achar ruins, mas que nem por isso são ilícitas. Se um indivíduo, na solidão das suas noites, bebe até cair desmaiado na cama, isso não parece bom, mas não é ilícito. Se ele fumar meia carteira de cigarros entre o jantar e a hora de ir dormir, tampouco parece bom, mas não é ilícito. Pois digo eu: o mesmo vale se, em lugar de beber ou consumir cigarros, ele fumar um baseado. É ruim, mas não é papel do Estado se imiscuir nessa área.

2. Violação à autonomia individual

A liberdade é um valor essencial nas sociedades democráticas. Não sendo, todavia, absoluta, ela pode ser restringida pela lei. Porém, a liberdade possui um núcleo essencial e intangível, que é a autonomia individual. Emanação da dignidade humana, a autonomia assegura ao indivíduo a sua autodeterminação, o direito de fazer as suas escolhas existenciais de acordo com as suas próprias concepções do bem e do bom. Cada um é feliz à sua maneira. A autonomia é a parte da liberdade que não pode ser suprimida pelo Estado ou pela sociedade.

Exs mais óbvios: o Estado e a sociedade não podem decidir com quem você vai se casar, qual deve ser a sua religião ou que profissão você vai seguir.

As pessoas têm, igualmente, o direito de escolher os seus prazeres legítimos. Há quem faça alpinismo, voe de ultraleve, participe de corridas de automóvel, ande de motocicleta ou faça mergulho submarino. Todas essas são atividades que envolvem riscos. Nem por isso são proibidas. O Estado pode, porém, limitar a liberdade individual para proteger direitos de terceiros ou determinados valores sociais. Pois bem: o